

プライバシーの権利Ⅲ

ー私的領域不侵入確保権ー

海野 敦史

G P S 捜査は、対象車両の時々刻々の位置情報を検索し、把握すべく行われるものであるが、その性質上、公道上のもののみならず、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間に関わるものも含めて、対象車両及びその使用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にする。このような捜査手法は、個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを侵害し得るものであり、また、そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着することによって行う点において、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり、公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである。

憲法35条は、「住居、書類及び所持品について、侵入、搜索及び押収を受けることのない権利」を規定しているところ、この規定の保障対象には、「住居、書類及び所持品」に限らずこれらに準ずる私的領域に「侵入」されることのない権利が含まれるものと解するのが相当である。そうすると、前記のとおり、個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるG P S 捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たる（中略）とともに、一般的には、現行犯人逮捕等の令状を要しないものとされている処分と同視すべき事情があると認めるのも困難であるから、令状がなければ行うことのできない処分と解すべきである。

GPS捜査事件判決から導かれる法理(Ⅰ)

「私的領域」の意義

- ・ 実質的にはプライバシーを意味すると明言する学説もある。
 - ・ 憲法35条1項の規定が財産的利益の保護も視野に入れていることにかんがみれば、各人のプライバシーに関わる領域に加え、個人の排他的支配が及ぶ固有の財産的利益を内包した領域も含まれるものと観念すべきなのではないか。
 - ・ 財産的利益に関する領域については、一定の私的財産及びそれが所在する物理的な空間が該当すると考えられる。
 - ・ プライバシーに関する領域については、住居と同様の私的空間として捉える考え方（**空間説**）と、物理的な領域だけでなく、個人の私生活等に関わる各種の情報の集積により形成される領域としても観念されるという考え方（**情報説**）がある。
- ⇒ 物理的侵入行為を伴う私的空間に対する不当な搜索等は住居不侵入等確保権により禁止される以上、私的領域不侵入確保権を保障する実質的な意義は、個人の行動の継続的かつ網羅的な把握を通じて当人の私生活等の相当部分を丸裸にする可能性及びそのために必要となる行為（情報の収集等）を公権力がみだりに実施する可能性からの保護にあるのではないか。

GPS捜査事件判決から導かれる法理(2)

⇒「私的領域」は、私生活に関わる場所・空間という物理的な領域のほか、私的情報等の集積により形成される観念的な領域も含む概念と考えられる。

・プライバシーに関わる「私的領域」には、私生活等に関わる場所・空間（私的空間）の現状から派生して、さまざまな場所における私生活上の平穏な状態（平穏状態）の確保された精神的な領域も含まれ得るのではないか。

←不当な搜索等又は搜索等近似行為の対象となること自体が、当人の平穏状態を急速に悪化させ、憲法35条1項が保護する国民の安心・安全を奪うことに結びつく。

・平穏状態の保護に対する要請は、私生活領域における各種の行為に対する公権力の不当な干渉・介入を排することを指向（憲法13条の要請に重なり合う）。

・以上を総合すると、プライバシーに関わる「私的領域」については、

① **私的空間**（物理的な領域）

② **私生活等における平穏状態**（精神的な領域）

③ **私生活等の相当部分を明らかにし得る私的情報等の集積**（観念的な領域）
で構成されると解される。

GPS捜査事件判決から導かれる法理(3)

GPS捜査事件判決にいう「侵入」の意義

- ・ GPS捜査事件判決上は、車両に対するGPS受信機器の装着自体が（所持品への）物理的な「侵入」とであると解する余地もある。
 - ・ しかし、その場合、住居不侵入等確保権の侵害が既に成立している中で、所持品に準ずる「私的領域」を観念する必要性が不明。
 - ・ 「個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間」（私的空間）での個人の行動を「継続的、網羅的に把握すること」を指すが、それだけでは「憲法の保障する重要な法的利益を侵害する」ことにはならず、所持品への物理的侵入の要素も併せて加味して初めて憲法35条1項の法益を侵害するものと解する余地もある。
 - ・ しかし、その場合、個人の行動を「継続的、網羅的に把握すること」を伴う監視型情報収集も、物理的侵入を伴わない限り広く許容され得ることとなり、今後の捜索等からの保護のあり方に問題を残す。
- ⇒ 収集・取得された情報の集積が私生活等の相当部分の把握に結びつくと認められる場合には、物理的侵入の有無にかかわらず、「私的領域への侵入」の可能性が肯定され得ると解されるのではないか。

GPS捜査事件判決から導かれる法理(4)

私的領域への「侵入」の意義

- ・学説上、物理的侵入を意味すると捉える考え方（**侵入狭義説**）と、物理的侵入だけでなく、私的情報等の収集・取得及びその後の利用・分析等を含めて広く観念されると解する考え方（**侵入広義説**）がある。
- ・「私的領域」の概念に関して、物理的な領域のほか、精神的・観念的な領域を含めて捉える限り、「侵入」についても、物理的侵入行為だけでなく、私的情報等の利用等を通じても成立し得ると解することが合理的。
- ・車両へのGPS受信機器の装着のように、物理的侵入の度合いとしては比較的軽微な行為もある中で、仮にそれが「侵入」の本質であれば、憲法35条1項にいう「住居、書類及び所持品」への古典的な侵入と位置づければ足りる。

※ 侵入広義説の思想に依拠するとしても、私的情報等の「搜索及び押収」については、物理的な空間を対象とする「侵入」とは区別されるという考え方もあり得る。

⇒ 搜索等については、侵入・搜索・押収のいずれの行為にも同様に令状主義の原則的要請が及ぶため、私的情報の利用等に関して「搜索及び押収」に該当する行為が認められれば、私的領域への「侵入」が成立すると解することが合理的。

GPS捜査事件判決から導かれる法理(5)

⇒私的領域への「侵入」の概念は、憲法35条1項にいう「侵入」の概念よりも、その射程が広い。

- ・私的領域への「侵入」は物理的侵入を介して初めて成立するという考え方もあり得る。
- ・しかし、（GPS受信機器の装着のような）物理的侵入の有無に応じて私的情報等の利用等に対する脅威の度合いが必ずしも著しく変化するわけではない（少なくともGPS受信機器の装着は、物理的侵入に伴う権利制約度としては比較的軽微）。
- ・物理的な侵入と私的情報の利用等とは別個の行為。よって、それらを「合算」して初めて「侵入」が成立すると解することも正鵠を射ていない。
- ・仮に物理的侵入を「侵入」が成立するための必要条件と捉える場合、それを伴わない私的情報の利用等による高度なプロファイリングが憲法35条1項との関係上問題とならない（ただし、憲法13条との関係では問題となり得る）という不合理な帰結。

⇒私的情報等の収集・取得のみでも、その態様によっては私的領域への「侵入」が成立し得ると解することが合理的（侵入広義説）。

※ただし、平穏状態の剥奪を伴う私生活等への介入（私的空間への物理的な侵入を伴うとは限らない）も私的領域への「侵入」に該当し得る。

GPS捜査事件判決から導かれる法理(6)

⇒侵入広義説の思想に基づく私的領域不侵入確保権の理解は、私的領域への「侵入」となり得る公権力の行為に多様な行為を包含する。

- ・侵入広義説は、私的空間（判例のいう「個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間」）から得られる私的情報の利用等を「侵入」と捉える考え方（**私的空間説**）と、公的空間か私的空間かを問わず、私的情報の利用等を通じて私生活等を実質的に監視する行為を「侵入」と捉える考え方（**監視説**）とに細分化される。
- ・監視説が妥当であり、その主な理由は以下のとおり。
 - ①公権力による私的情報の利用等は、その収集・取得の場が公的空間か私的空間にかかわらず、当人の自律的な私生活に影響を及ぼし得る
 - ②私的空間で得られる情報の一部については、公的空間でも同様に取得可能となり得る
 - ③そもそも公的空間と私的空間との規範的な区別は決して一義的なものではない
- ・監視説の要諦は、私的情報の収集・取得がただちに「私的領域への侵入」となるのではなく、利用・分析等の可能性も踏まえた結果として、各人の私生活等を実質的に介入又はそれを監視するほどに、その様相の相当部分を明らかにする「監視能力」が認められるか否かに応じて「私的領域への侵入」の有無を判断すること。

GPS捜査事件判決から導かれる法理(7)

・以上を総合すると、プライバシーの観点からの私的領域への「侵入」は、公権力が正当な手続によらずに以下の行為を行った場合に成立する。

- ① 私的空間への物理的侵入行為を通じてその現状に変更を加えた場合
- ② 平穏状態を妨害しつつ私生活等に介入した場合
- ③ (特定の者の) 私的情報の収集・取得及び利用により、私生活等の相当部分を明らかにし得る水準での実質的な「監視」を行っていると認められる場合

・このように広範に「私的領域への侵入」を観念する限り、該当する公権力の行為は多様化し、非刑事手続の局面にも及び得る。それゆえ、憲法35条1項に基づき私的領域不侵入確保権が保障されるという考え方は、同条項をあらゆる公権力の行使への適用を視野に入れた実体的権利を保障するものと解する思想（実体的権利説）に整合的。

※ 情報の収集・取得により**私生活等の相当部分を丸裸にする蓋然性を生む状態の作出**それ自体が「侵入」となる（実際に私生活を丸裸にしたか否かは問われない）。

⇒ 例えば、ごみ集積所に出されたごみの領置（最決平成20年4月15日刑集62巻5号1398頁）は、一般に私生活の様相の相当部分を明らかにする能力が肯定されがたく、それが不当に実施されるものではない限り、「私的領域への侵入」に該当しない。

GPS捜査事件判決から導かれる法理(8)

- ・ 以上の考え方に照らせば、判例で問題となったGPS捜査に関しては、当人の位置情報の継続的かつ網羅的な把握によりその私生活等の相当部分を明らかにし得る状態を作出する契機となるGPS受信機器の「装着」の時点が、「侵入」の着手時点。

⇒GPSによる位置情報収集の潜在的な監視能力をあらかじめ見越しつつ、上記状態を作出する端緒となる行為が完了した時点で、「侵入」が成立。

- ・ 「装着」という物理的侵入自体は（非物理的侵入行為たる「監視」の）着手時点にほかならず、**「侵入」の本質はあくまで私生活等の相当部分を明らかにし得る状態の作出（監視）。**

※ただし、私的情報の取扱いに関しては、情報の種類によっては、当人の私生活等の相当部分を丸裸にし得るか否かを必ずしも問わずに「私的領域への侵入」に該当する例外的な場合も考えられる（憲法が直接保護する情報：携帯電話端末等の「所持品」に内包された情報、通信の秘密を構成する情報等）。

私的領域の保護の意義

- ・ プライバシーに関わる領域としての「私的領域の保護」には、以下に示す各保護法益が複合的に含まれている（これとは別に、財産的利益もある）。

①私的空間それ自体の保護（**狭義の私的空間保護**）

住居及びこれに準じた一定の私的空間について、公権力により適正な手続によることなく物理的に破壊されたり、無断で現状を変更されたりしないことに対する利益

②一定の空間で、本来の平穏状態を奪われないことの最大限の確保（**平穏状態保護**）

私生活の局面は公的空間にも及び得るため、所在する空間を問わず、身の周りの搜索等により当人の私生活領域における平穏状態が奪われる可能性から防御される利益

③当人の所在する空間を問わず、その私的情報に関して、公権力による適正な手続を経ない形での利用等の脅威から防御された状態の確保（**私的情報等不当利用等防御**）

私的情報等の不当な収集・取得及びその後の利用、開示等を通じた、当人の私生活等の相当部分が把握される可能性の発現防止に対する利益。特に、空間の壁を越えて私的情報等の収集等を行う「空間超越的な侵入」からの保護を指向。

GPS捜査事件判決から導かれる法理(10)

- ・ 私的情報の収集・取得後に行われる事後的な利用・分析等の行為は、それが情報の収集・取得と可分的である限りは、私的領域への「侵入」に該当するものではない。一定の態様での情報の収集・取得が行われ得るようになった時点で既に「侵入」は成立。
- ・ しかし、情報の収集・取得と利用・分析等とは一連の過程であることが一般的なため、情報の利用・分析等は「侵入」に付随する行為（**侵入付随行為**）と位置づけられ得る。
- ・ 私的情報等不当利用等防御との関係における公権力の行為の統制を考えるに当たっては、「侵入」と侵入付随行為との規範的な径庭を考える余地はあるものの、その統制に関する規律の基軸は「侵入」におかざるを得ない。
- ・ なお、侵入付随行為には、収集・取得した情報を内部的に保管及び利用する行為と、その情報を第三者に提供又は開示する行為とに大別される。
- ・ 第三者への提供・開示については、内部的な保管・利用よりも概して権利制約度が強いため、「**個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由**」（最判平成20年3月6日民集62巻3号665頁）との関係も踏まえ、立法論上より厳格な統制が求められ得る。

プライバシーの利益の再構成（Ⅰ）

憲法35条 1 項に基づく私的領域不侵入確保権

- ・ 憲法35条 1 項の規定は、プライバシーを保護する一次的な根拠条項。
- ・ **憲法上のプライバシー保護とは、①狭義の私的空間保護、②平穏状態保護、③私的情報等不当利用等防御の各要素をその核心とする**ものとして再構成され得る。
- ・ よって、プライバシー保護に関して、憲法13条の規定の要請を重畳的に持ち出す必要性は低い。幸福追求権の保障は基本的に「補充的保障」であり、個別の基本権に関する規定に根拠を有しない基本権を包括的に保障するという前提に立つ限り、私的領域不侵入確保権を差し置いてまで、同条の適用を問題とする必要性は乏しい。
- ・ 「私的領域」は当人が自ら「コントロール」することを予定しない。特に、平穏状態保護や私的情報等不当利用等防御の側面は、一定の環境や情報の集積により形成される状態への不介入の確保を指向。当人によって平穏状態が統御されたり、公権力による私的情報等の利用等の程度が決められたりするわけではない。
- ・ それゆえ、「私的領域」の保護のあり方は、**公権力による行為が一定の機能的な水準の範囲内にとどまり、当該領域への「侵入」に該当しないと認められるか否かの客観的な観点を踏まえて行われることが合理的**。

プライバシーの利益の再構成(2)

- ・なお、「私的領域」の保護に対する要請は、プラットフォーム事業者等の大量に私的情報を取り扱う私人（**大量情報取扱私人**）による情報収集その他の「私的領域への侵入」に匹敵すると認められる行為（**私的領域侵入相当行為**）に対して完全な無関心を貫くものではない。
- ・少なくとも、公権力が大量情報取扱私人の助力を得て権利制約度の強い情報収集を実施する場合には、憲法35条1項の趣旨に背反する「私的領域への侵入」の可能性が正面から問われる。
- ・また、**一定の大量情報取扱私人による私的領域侵入相当行為を通じて私的領域不侵入確保権の侵害に準じた状態が構造的に発生し得ると認められる場合**には、それが憲法の予定する個人の尊厳や自律を脅かし得ることに照らし、かかる行為への立法上の規律（個人情報保護法等）に対する要請についても、憲法35条1項に基礎づけられ得る。
- ・憲法31条に基づく適正な法定手続の保障の射程に関して、「自由を剥奪する行為にほぼ匹敵する行為が公権力以外の者により行われる蓋然性が構造的に顕在化していると認められる場合」も含めて解すれば、同条の趣旨を媒介として、私的領域侵入相当行為に対する立法上の規律を憲法35条1項の規定の要請と捉えることの合理性は高まる。

【憲法31条】

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

プライバシーの利益の再構成(3)

私的領域不侵入確保権と自己情報コントロール権との相違

- ・自己情報コントロール権説の下では、プライバシー外延情報については、その保護が不十分となるおそれを秘めている一方、私的情報等不当利用等防御はかかる情報が機微な私的情報と結合して利用される可能性も勘案し、一定の範囲で保護の網をかぶせる。
- ⇒私的情報等不当利用等防御においては、収集・取得対象の情報をプライバシー固有情報とプライバシー外延情報とに二分する視点を排し、両者を包含した私的情報の利用等が当人の私生活等の相当部分の把握に至り得る蓋然性（監視能力）を有しているか否か、また正当な目的・理由に根ざす適正な手続に基づき行われているか否かを問題とする。
- ・「自己情報のコントロール」（その実現のための公権力による無断での取得・利用・開示等の包括的な禁止）は物理的に不可能に近い一方、私的情報等不当利用等防御は、かかる「コントロール」に対応した私的情報の利用等の全般的な抑止を指向せず、当人の私生活等の相当部分の把握に結びつくと認められる形での不当な利用等を禁止。

プライバシーの利益の再構成(4)

⇒私的情報等不当利用等防御の側面に関しては、以下の各点を含意する。

① 機微な私的情報の高度な解析等を通じた利用等であっても、正当な目的・理由に裏づけられた適正な法定手続に基づくものである場合には許容され得る。

② 前記①の場合でも、把握された情報の公開又は第三者への提供については別途の考慮を要する可能性がある（当然に許容されるわけではない）。

③ 私生活等の相当部分の把握に至り得ると認められる形での私的情報の利用等は、前記①の場合を除いて禁止される。

④ 前記③で禁止される水準に至らない態様での私的情報の利用等は、不当又は不合理なものでない限り、基本的に許容される。

・私的情報等不当利用等防御における「私的情報の利用等が当人の私生活等の相当部分の把握に結びつくと認められるか否か」は、自己情報コントロール権説が問う「自己情報が当人によるコントロールの範囲を超えて利用等されているか否か」とは別問題。

⇒前者は基本的に情報収集の規模や期間を踏まえた公権力の客観的な監視能力を問いつつ、それに応じて一定の態様での私的情報の把握を端的に禁止するのに対し、後者は当人の主観的・可変的な「コントロール」の及ぶ射程を観念。

プライバシーの利益の再構成(5)

憲法13条と憲法35条1項との関係

- ・学説上、憲法35条1項は憲法13条の「特別規定」として位置づけられると解する考え方（特別規定説）もある。これによれば、私的領域の不可侵は、プライバシー保護という命題の中でも特に要保護性が強いために憲法35条1項で保障され、それ以外の「水面下に隠れている」プライバシーの要素が憲法13条により保護されるという。
- ・しかし、憲法13条と個別基本権規定との関係は、「一般法と特別法との関係」というよりも、「基本法とその具体化法との関係」に近い。
- ・憲法13条後段（幸福追求権）が措定するプライバシーの要素（「私生活領域にみだりに介入されないことに対する権利」や「私的情報がみだりに取り扱われないことに対する権利」の要素）については、私的領域不侵入確保権において包括的に具体化。
- ・よって、私的領域不侵入確保権とは別に、補充的保障を旨とする幸福追求権の一環として、上記要素を特定する（具体的な主観的権利として位置づける）意義が希薄。
- ・憲法13条の「特別規定」として憲法35条1項の規定を枠づけようとする、私的領域不侵入確保権の保護が矮小化されることとなるおそれも。憲法13条後段は、プライバシー保護の一般原則的な要請として、公権力の行為を一定の範囲で統制するにとどまるため、多層的な「私的領域」の保護法益をくまなく網羅するものとは言い切れない。

プライバシーの利益の再構成(6)

- ・ただし、決して憲法13条と憲法35条1項とは「断絶」されているわけではない。
- ・公権力の行使が「公共の福祉」の確保に必要な範囲を超え、私的領域が侵され始めると、収集された私的情報のプロファイリングを通じて形成される不正確なデータの「一人歩き」によって当人に対する各種の重要な決定が当人に不利益となる形で一方的に行われるなど、**個人の尊重の原理**にも重大な影響が及ぶ状況が出現。
- ・よって、私的領域不侵入確保権の保護は、特に私的情報等不当利用等防御の要素を接点として、個人の尊厳及び人格的自律の確保に対する憲法13条前段の要請にも接続。
- ・また、私的領域不侵入確保権に対する制約のあり方は、令状主義との関係だけでなく、憲法13条後段にいう「公共の福祉」との関係で定まる側面も有するため、憲法13条は、憲法35条1項に基づく私的領域不侵入確保権の保護（その一環としてのプライバシー保護）を側面的に支援。
- ・憲法13条は、私的領域不侵入確保権の保護のあり方を問う際に、①**個人の尊厳及び人格的自律との関わりの深い私的情報の取扱いには特に慎重な対応**が求められ得る、②**権利の「最大の尊重」と「公共の福祉」の確保とのバランス**を考慮すべき、という命題を付与。

憲法21条2項後段の保護法益

憲法21条の規定

- 1 項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 項 検閲は、これをしてはならない。**通信の秘密は、これを侵してはならない。**

憲法21条 2 項後段の規定の意義

- ・「通信」について明示的に定めた唯一の憲法規範であり、「通信」の根本規範。

【参考：憲法98条 1 項】

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

- ・国民各人において「通信」が安定的に行われることを予定しており、「秘密」の保護の前提として、「通信の自由」を保障し、憲法適合的な通信制度の設営を要請。
- ・「通信」が成立するためには、**通信当事者**（情報の発信者ないし当初の送信者及びその着信者ないし最終的な受信者）の行為に加え、通信事業者等（**通信管理主体**）による通信用ネットワークの設営とその接続、ネットワーク上における最低限の安全性・信頼性ないしセキュリティ、国民生活に不可欠となる「基本的な通信役務」の適切な提供といった多様な要素を総合的に、通信制度の下で確保することが不可欠。

憲法21条2項後段と同35条1項の共通点と相違点(1)

共通点

- ・公権力に対する禁止規範としての性格を有しつつ、各人の基本権（通信の秘密を侵されない権利及び通信の自由又は私的領域不侵入確保権）を保護する側面を有する。
- ・プライバシー利益を確保する観点からの一定の制度形成を要請していると解される。

相違点

- ・プライバシーは私人間でも問題となり得るが、憲法上の通信の秘密は一定の「信頼」を有すると認められる相手（公権力及び通信管理主体）との間でのみ発生。
- ・私的情報等不当利用等防御の観点からプライバシー保護が問題となる情報は主に「私的情報」だが、通信の秘密として保護される情報は私的情報か否かを問わない。
- ・一般的な私的情報については公権力による一定の態様での利用等が許容され得るが、通信の秘密として保護される情報に対しては公権力において接しないことが原則。
- ・一般的な私的情報については、私生活等の相当部分を明らかにし得る水準で集積されない限り、必ずしも「私的領域への侵入」に該当するものではないが、通信の秘密として保護される情報については、公権力等により正当な理由なく探知された途端に「侵害」が成立し得る。

憲法21条2項後段と同35条1項の共通点と相違点(2)

相違点：続き

- ・ 憲法上、通信の秘密を保護することが予定された主体には公権力のほか通信管理主体が含まれる一方、私的領域不侵入確保権を直接保護する主体は公権力に限定。
 - ※ 大量情報取扱私人による私的領域侵入相当行為は、立法を通じた一定の規律を求め得るが、公権力による「私的領域への侵入」とは規範的に区別される。
- ・ 通信においては、発信者と着信者との間で通信管理主体が一定の仲立ちを行うことが行為の成立に不可欠で、「秘密」たる情報を直接取り扱う通信管理主体が必然的に公権力に準じた立場に立つが、「私的領域への侵入」は基本的に公権力の行為。
 - ⇒ 私的領域不侵入確保権の保障は、必然的に、通信の秘密の保護とは異なる固有の側面（特に、手続的権利の保護という側面）を有する。